

1501894-63.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194 - Jardim Claudia

CEP: 08577-010 - Itaquaquecetuba - SP

Telefone: 4640-3454 - E-mail: itaqua1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1501894-63.2022.8.26.0616 - p.

SENTENÇA

Processo nº:

1501894-63.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

AELTON DE JESUS FERREIRA e outro

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra AELTON DE JESUS FERREIRA e ROSILAINE FERNANDES DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos no artigo 33, "caput", cc. o art. 41, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, foram denunciados e estão sendo processados, porque no dia 12 de agosto de 2022, por volta de 13 horas, na Rua Tocantins, altura do nº 21, nesta cidade e Comarca, os denunciados, agindo em concurso, evidenciando pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, supostamente traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, sem autorização, 30 invólucros de cocaína (com peso 17,52 gramas), 37 invólucros de crack (com peso de 2,44 gramas) e 53 invólucros de maconha (com peso de 131,76 gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 24/25 e laudo de constatação de fls. 14/17. Os denunciados foram notificados às fls. 124 e 130, ofereceram defesa prévia às fls. 127 e 153. A denúncia foi recebida fls. 155/156. Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, os réus foram interrogados.

Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal

fundamentando-se na insuficiência probatória que entende ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva não merece ser acolhida.

A despeito da prova de materialidade delitiva estar devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão às fls. 04, pelo laudo de constatação provisória às fls. 12/15 e através do laudo toxicológico definitivo às fls. 119/121, a prova é falha.

A testemunha MICHELE LIMA DA SILVA, guarda civil metropolitano, relatou que na data dos fatos receberam denúncia dos fatos via CECOM (telefone à guarda municipal) noticiando que um casal estaria comercializando entorpecentes na Rua Tocantins, Parque Viviane. Assim, ao entrar na indicada rua visualizou um casal que ao perceber a viatura começou a caminhar em sentido contrário.

Identificados os réus, Rosilaine carregava 04 (quatro) papelotes de substância parecida com cocaína e Aelton portava 07 (sete) papelotes de substância parecida com maconha e a quantia em dinheiro que não se recorda. Confessaram a prática delitiva. O réu Aelton ainda indicou um terreno baldio onde as substâncias estariam em meio ao matagal, razão pela qual foram encontradas as substâncias entorpecentes. Por fim, afirmou que o local dos fatos fica cerca de 500 metros da Escola Estadual Parque Viviane.

Indagada acerca da sacola encontrada com entorpecentes, não soube descrever e disse que o terreno distava cerca de 10 metros do local em que o casal foi preso.

A testemunha MARCOS ROBERTO CORREA DE MORAES, guarda civil metropolitano, teceu declarações no mesmo sentido de sua colega de farda, Michele relatando as circunstâncias de espaço e tempo já apontadas. Acrescentou que havia dois homens próximos deles que também foram abordados. Disse que a escola ficava na "rua de baixo".

O réu AELTON DE JESUS informou que vive em união estável com Rosilaine. É usuário de entorpecentes, negou a prática delitiva. Ostenta antecedentes, mas não vende drogas. Relatou que apenas havia saído até a padaria e que Rosilaine foi abordada em momento separado. Disse que o traficante chegou a ser abordado, mas não o levou porque era o interrogando quem ostentava antecedentes.

Já havia tido confusão com ele anteriormente porque ele havia abordado sua esposa e não havia permitido. Trabalha na empresa "Caio Uniformes" como cortador de tecido. Estava em período de testes.

A ré ROSILAINE FERNANDES DOS SANTOS, perante a autoridade policial, manifestou interesse em permanecer em silêncio, acrescentando tão somente que não sofreu agressão por parte dos policiais.

Trabalha em um sítio fazendo limpeza no local. É esposa de Aelton. São usuários de drogas. Foram buscar drogas naquele momento. Estavam até acompanhados do cachorro. Os guardas municipais chegaram ao local e abordaram todos que ali estavam inclusive dois homens que pegavam lixo reciclável.

Passo a valorar a prova

A prova é de extrema fragilidade para tráfico de drogas e, ademais, possui caráter ilícito, senão vejamos.

Os réus foram encontrados na posse de 4 porções de cocaína (Rosilaine) e 7 porções

de maconha (Aelton) bem como quantia em dinheiro.

Nada mais.

Os guardas municipais não foram uníssonos em afirmar onde foi encontrada a sacola que continha mais entorpecentes. A guarda municipal Michele afirmou que estava em terreno há cerca de 10 (dez) metros do local em que estavam os acusados. O guarda municipal Marcos Roberto afirmou que estava jogada em terreno, tal como se tivesse sido dispensada rapidamente.

Fato é que o grande volume de drogas – aquele encontrado na sacola – não estava na posse dos acusados e nenhum ato de traficância foi presenciado pelos guardas municipais.

Por fim, ambos se disseram usuários de drogas e, Aleton, de sua vez, relatou ter atividade profissional lícita indicando a empresa e a função em que trabalhava antes de ser preso.

Nesse contexto e considerada a quantidade de drogas encontrada na posse dos acusados, não se vislumbra a ocorrência efetiva do delito de tráfico de drogas. A prova dos autos seria suficiente somente para indicar a ocorrência do delito de porte de porte de entorpecente para consumo próprio, contudo, ante a flagrante atuação investigativa da guarda municipal e, portanto, ilegalidade da prisão, a absolvição é medida que se impõe.

No presente caso, os guardas civis que procederam à prisão em flagrante do acusado extrapolaram os limites de suas funções, já que atuaram sem visar à proteção dos bens, serviços e instalações do Município de Itaquaquecetuba (arts. 144, § 8º, da Constituição Federal e 2º, 4º e 5º, inciso II, da Lei nº 13.022/2014).

É cediço que deve existir fundada suspeita que justifique a realização de busca pessoal, de modo que deve haver elementos concretos que impliquem suspeita de prática criminosa, não sendo permitido às guardas municipais realizar busca pessoal como decorrência de atividade de investigação criminal.

No presente caso, a atuação dos guardas municipais não se baseou em nenhuma das hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal, mas em atitude típica de investigação policial, já que afirmaram terem recebido telefonema anônimo que indicava um casal vendedor de drogas. Os entorpecentes foram encontrados após realização de busca pessoal, o que constitui verdadeira atividade de investigação que extrapola as competências constitucionais e legais previstas para as guardas civis municipais.

O crime de tráfico ilícito de drogas ora imputado ao acusado, embora seja crime permanente, só foi constatado depois da revista pessoal pelos guardas civis, que não são policiais, o que evidencia a irregularidade por ausência de causa justa e prévia. Nesse cenário, tem-se que a busca pessoal foi realizada em atividade ostensiva de policiamento em via pública, o que não se coaduna com as funções dos guardas civis.

A respeito do tema, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal de 1988 não atribui à guarda municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, como se fossem verdadeiras “polícias municipais”, mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. A exclusão das guardas municipais do rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (incisos do art. 144 da Constituição) decorreu de opção expressa do legislador constituinte “apesar das investidas em contrário” por não incluir no texto constitucional nenhuma forma de polícia municipal.

2. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil “em contrapartida à possibilidade de exercerem a força pública e o monopólio estatal da violência” estão sujeitas a rígido controle correcional externo do Ministério Público (art. 129, VII, CF) e do Poder Judiciário (respectivamente da Justiça Militar e da Justiça Estadual). Já as guardas municipais “apesar da sua relevância” não estão sujeitas a nenhum controle correcional externo do Ministério Público nem do Poder

Judiciário. É de ser ver com espanto, em um Estado Democrático de Direito, uma força pública imune a tais formas de fiscalização, a corroborar, mais uma vez, a decisão conscientemente tomada pelo Poder Constituinte originário quando restringiu as balizas de atuação das guardas municipais à vigilância do patrimônio municipal.

3. Não é preciso ser dotado de grande criatividade para imaginar “ em um país com suas conhecidas mazelas estruturais e culturais “ o potencial caótico de se autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha sua própria polícia, subordinada apenas ao comando do prefeito local e insubmissa a qualquer controle externo. Ora, se mesmo no modelo de policiamento sujeito a controle externo do Ministério Público e concentrado em apenas 26 estados e um Distrito Federal já se encontram dificuldades de contenção e responsabilização por eventuais abusos na atividade policial, é fácil identificar o exponencial aumento de riscos e obstáculos à fiscalização caso se permita a organização de polícias locais nos 5.570 municípios brasileiros.

4. A exemplificar o patente desvirtuamento das guardas municipais na atualidade, cabe registrar que muitas delas estão alterando suas denominações para “Polícia Municipal”. Ademais, inúmeros municípios pelo país afora “ alguns até mesmo de porte bastante diminuto “

estão equipando as suas guardas com fuzis, equipamentos de uso bélico, de alto poder letal e de uso exclusivo das Forças Armadas.

5. A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem do suspeito.

6. Ao dispor no art. 301 do CPP que “qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes.

7. Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais, também não são cidadãos comuns. Trata-se de agentes públicos com atribuição sui generis de segurança, pois, embora não elencados no rol de incisos do art. 144, caput, da Constituição, estão inseridos § 8º de tal dispositivo; dentro, portanto, do Título V, Capítulo III, da Constituição, que trata da segurança pública em sentido lato. Assim, se por um lado não podem realizar tudo o que é autorizado às polícias, por outro lado também não estão plenamente reduzidos à mera condição de “qualquer do povo”; são servidores públicos dotados do importante poder-dever de proteger o patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações.

8. É possível e recomendável, dessa forma, que exerçam a vigilância, por exemplo, de creches, escolas e postos de saúde municipais, de modo a garantir que não tenham sua estrutura física danificada ou subtraída por vândalos ou furtadores e, assim, permitir a continuidade da prestação do serviço público municipal correlato a tais instalações. Nessa esteira, podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais “ e por isso interpretadas restritivamente “ nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária.

10. Na hipótese dos autos, os guardas municipais estavam em patrulhamento quando depararam com o recorrente sentado na calçada, o qual, ao avistar a viatura, levantou-se e colocou uma sacola plástica na cintura. Por desconfiar de tal conduta, decidiram abordá-lo e, depois de revista pessoal, encontraram no referido recipiente certa quantidade de drogas que ensejou a prisão em flagrante delito.

11. Ainda que eventualmente se considerasse provável que a sacola ocultada pelo réu contivesse objetos ilícitos, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado.

Caberia aos agentes municipais, apenas, naquele contexto totalmente alheio às suas atribuições, acionar os órgãos policiais para que realizassem a abordagem e revista do suspeito, o que, por não haver sido feito, macula a validade da diligência por violação do art. 244 do CPP e, por conseguinte, das provas colhidas em decorrência dela, nos termos do art. 157 do CPP, também contrariado na hipótese.

12 . Recurso especial provido.

(REsp n. 1.977.119/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)

Por conseguinte, constatado que houve o desempenho de nítida atividade de investigação pelos guardas civis, que desborda da situação de flagrância, deve ser reconhecida a invalidade das provas dela decorrentes e, conseqüentemente, o réu deve ser absolvido.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, deixo de acolher a pretensão punitiva estatal, JULGO IMPROCEDENTE o pedida da denúncia e, conseqüentemente, ABSOLVO os réus das imputações constantes da denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura em relação ao réu AELTON DE JESUS PEREIRA.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. R. I.

Itaquaquecetuba, 19 de outubro de 2022.

Érica Pereira de Sousa

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA